

1505736-46.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... de pessoas facilitar o crime de tráfico de drogas; não incide a diminuição do tráfico privilegiado porque ele responde a uma acusação de tráfico de drogas no Paraná; não é cabível a substituição da pena por restritiva de direito e deve ser fixado o regime inicial fechado.

A douta Defesa pleiteou a absolvição do réu. Sustentou que: o réu recebeu uma mensagem de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505736-46.2021.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505736-46.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331811/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 21802136 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 5199/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2331811 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSÉ MARIA DE SOUZA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra José Maria de Souza Junior, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. Narrou que no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 21h, na Rua José Francisco Giorgi Junior, nº 169, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca, José Maria, guardava e tinha em depósito 11,43g de cocaína, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como adquiriu um celular, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado em atitude suspeita defronte a sua residência, já conhecida como ponto de comércio de drogas, motivo pelo qual abordaram; em revista pessoal localizaram um celular Samsung, que constatou-se ser produto de crime; em revista pela residência, autorizada pelo denunciado, os policiais localizaram num quarto, em cima de um "rack", 17 porções de cocaína, envoltas em plástico transparente, e balanças de precisão.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls.137/146).

A denúncia foi recebida em 09/02/2022 (fls.106/107).

Foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu (fls.171/172).

Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação sob os argumentos de que o crime anterior foi provado pelo registro de ocorrência de fls.13/14; o celular foi encontrado na posse do réu; o contexto indicado pela prova revela que o acusado recebeu a posse em circunstâncias que indicam ter a plena ciência da origem ilícita; os policiais disseram que estava na posse do réu na via pública e não tinha caixa ou documentos originais do fabricante; o réu disse que recebeu de Buiú; a apreensão do produto ilícito faz gerar a inversão da posse, cabendo ao réu comprovar a aquisição lícita, mas nada foi apresentado; os policiais afirmaram que abordaram o réu na posse do celular produto de furto, depois a esposa da Aline autorizou diligências no interior do imóvel e lá localizaram 17 porções de cocaína junto de duas balanças de precisão num rack; as drogas estavam divididas em porções prontas para venda; a apreensão das balanças junto das drogas indicam a traficância; o réu apresentou versões distintas nas vezes em que inquirido, na fase policial e na companhia da dra. Andressa deu versão diversa e admitiu que pesava drogas; é inverossímil que um usuário tivesse drogas para ver se estava sendo enganado pelo traficante; embora tenha sustentado que falou isso por ter sido agredido o réu estava na presença de sua advogada e não se cogita que a Autoridade Policial tenha feito ajuste com a Advogada; no depoimento o réu deu vários detalhes contra os policiais e narrou inclusive a irregularidade da assinatura da declaração de fl.15; a companheira foi ouvida na condição de informante e não há indicativo concreto de que sofreram agressões; o laudo de corpo de delito de fl.28 indica a inexistência de lesão no réu; Aline não registrou nenhum crime perante a Autoridade Policial; não há elementos que infirmem a palavra dos policiais; o réu estava em Assis há pouco tempo e disse não ter problema com os policiais; deve ser aumentada a pena pela agravante do crime durante período de pandemia, seja pelo aumento de consumo, seja pela redução de circulação de pessoas facilitar o crime de tráfico de drogas; não incide a diminuição do tráfico privilegiado porque ele responde a uma acusação de tráfico de drogas no Paraná; não é cabível a substituição da pena por restritiva de direito e deve ser fixado o regime inicial fechado.

A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu. Sustentou que: o réu recebeu uma mensagem de que o lanche que pediu estava chegando, abriu a porta da residência e se deparou com os policiais; a quantia de droga era destinada ao uso próprio do réu e de sua amásia; o réu não tinha ciência da origem ilícita do celular; os policiais ingressaram sem autorização para acesso na casa, articularam armadilha para obter provas de quem roubou o celular e agrediram o casal para conseguirem a informação desejada; os policiais pretenderam prejudicar o réu quando declarou que não o encontrou com Renato Cyman, pessoa a quem tentaram prejudicar; o policial alegou não precisar da permissão assinada para fazer a busca na residência; não havia razões para acreditar que José Maria estava cometendo um crime permanente, os policiais já sabiam quem havia furtado o dispositivo; a posse do celular não justificava a invasão na residência; Aline assinou um documento ao final da abordagem, sem seu conhecimento, policiais dobraram o documento para ela não ler; Aline ficou com medo de dizer na Delegacia que os policiais haviam ameaçado e agredido; a Advogada que presenciou o depoimento não iria se opor ao cliente assumir a traficância por não querer que a esposa fosse detida; não há provas de que o réu traficava; o depoimento dos policiais deve ser visto com reservas; deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo; no caso de condenação o réu faz jus à

atenuante da menoridade relativa e ao tráfico privilegiado no patamar máximo. Pediu o desentranhamento da prova obtida de maneira ilícita, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena por restritiva de direito e a isenção do pagamento de multa (fls.179/210).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e receptação foi provada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.09/12 e 13/14), auto de exibição e apreensão (fls.16/17), laudo preliminar (fls.22/24), e laudo de exame químico de entorpecente (fls.74/76). Consta neste que foi periciada substância pulverizada, com resultado positivo para cocaína, substância indicada em lista proibitiva no Brasil. A autoria também é certa e atribuída ao requerido, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório José Maria negou o crime. Afirmou que estava em casa com a esposa, ela pediu um lanche e receberam mensagem que estava na frente. Relatou que foi buscar e os policiais deram socos e chutes e quebraram um rodo no depoente e o soldado Rocha bateu na esposa. Mencionou que eles pediram o celular que estava carregando. Declarou que eles pediram para dizer que tinha comprado do Renato Cyman, que se confirmasse eles o liberariam, mas não conhece essa pessoa. Salientou que depois foi levado para a Civil, lá deram esse papel para assinar, mandaram assinar rápido. Negou ter lido o que estava escrito porque eles mandaram assinar rápido. Disse que comprou esse celular por R\$ 500 e pagou R\$ 100, disse que falou ao rapaz que quando entregasse a nota pagaria o resto. Negou saber que o aparelho era furtado. Falou que comprou de um tal de "Buiú", que cata reciclagem com o depoente, a pessoa não voltou para receber e trazer a nota. Negou ter sido abordado por policial em Assis, não conhece nada aqui. Frisou que as balanças estavam no bag de reciclagem e nem prestavam. Narrou que comprou a droga de uns rapazes na Praça Prudenciana porque é usuário, pagou R\$ 250. Ressaltou que usaria essa droga com a esposa em uma semana. Contou que o policial Rocha e outros falaram para dizer que as balanças eram da droga, senão prenderiam sua esposa e levariam a enteada ao Conselho Tutelar, então admitiu que eram suas. Ressaltou que os policiais estavam perto e o depoente comentou sobre as agressões, estava com a boca sangrando e mostrou ao rapaz que faz o "corpo de delito". Disse ter escutado os tapas do policial na sua esposa. Esclareceu que os policiais lhe obrigaram a falar que traficava. Afirmou que fazia quatro meses que morava nessa casa e nunca havia sido abordado por policiais. Relatou que policiais fizeram gravar um vídeo autorizando o ingresso na casa, se recusou e levou um soco na barriga. Negou ter sido abordado na rua. Negou ter baterias nas balanças. Mencionou ter mostrado a lesão na boca e na costela ao médico. Disse que o policial Rocha estava na porta da sala do delegado durante o depoimento. Falou que no Paraná a polícia invadiu, foi carregado com 9 balas de 380, não tinha drogas. Ressaltou que fazia bicos como encanador de piscina e recolhe reciclagem, ganha R\$ 80 por dia e mais R\$ 1200 pela reciclagem.

A testemunha João Alex afirmou que estavam em patrulhamento quando avistou o réu na esquina da casa dele em atitude suspeita, abordaram e localizaram um celular na posse dele. Relatou que constataram pelo IMEI que era produto de furto e o réu admitiu que adquiriu de Renato Cyman, o autor do furto em um estabelecimento comercial na mesma data. Mencionou que como o local é conhecido por tráfico entraram na casa, com consentimento do réu, e acharam 17 porções de cocaína envoltas em plástico e duas balanças de precisão. Contou que o réu assumiu o tráfico e que venderia a porção por R\$ 30 a unidade. Negou que alguém tenha ferido a integridade física ou moral do réu. Disse que aquele local era conhecido por tráfico e nos últimos dois meses tinham informações de que o réu traficava naquele local, o patrulhamento lá era motivado por estas denúncias. Ressaltou que houve o consentimento da dona Aline, que percebeu a viatura e consentiu com a entrada, da

mesma forma que o réu. Frisou que quando ele consentiu com a entrada pediu ao réu que conferisse os dados na declaração e após fizeram a incursão. Negou que ele tenha assinado na Delegacia. Negou que Aline tenha ido até a Delegacia, perceberam que era o réu o traficante. Informou que ainda que não houvesse situação de flagrante poderiam entrar porque havia outros objetos para apreender, mas ainda tomaram a cautela de preparar a declaração. Disse que mostrou o papel, eles leram e assinaram. afirmou que foram várias denúncias de tráfico nos últimos meses em desfavor do réu, já vinham saturando por vários dias na tentativa de fazer o flagrante. Relatou que essa foi a primeira vez que abordaram. Negou ter obrigado o réu a falar que adquiriu o celular de Renato Cyman. mencionou que o réu disse conhecer o Renato e esta pessoa mora há duas quadras do réu. Negou ter ficado sabendo quanto o réu pagou pelo celular. Negou ter tido acesso ao celular do réu e esposa. Negou ter percebido resquício de cocaína na balança. Declarou que num primeiro momento foi uma viatura policial, depois chegou outra equipe, não se lembra se entraram na casa. Negou se lembrar de ter pedido para gravar vídeo com a autorização de entrada. Negou ter outras pessoas além do réu e esposa. Negou ter tido acesso ao celular de Aline.

Tais informações foram confirmadas pelo policial Rômulo. Acrescentou que ao ver a viatura ele demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente na casa. Relatou que o réu confirmou ter adquirido o celular de Renato Cyman, conhecido por furtos. mencionou que aquele celular foi furtado de uma clínica na mesma data. Declarou que o réu e a companheira Aline assinaram termo de autorização da busca. Confirmou a localização de 17 porções de cocaína e duas balanças de precisão no rack. Disse que o réu confessou o tráfico e no caminho até a Delegacia ficava a casa de Renato Cyman, a qual estava vazia. Frisou que ao lado havia um terreno baldio onde acharam a televisão. Ressaltou que fizeram contato com a vítima do furto, ela reconheceu a tv e o celular como objetos furtados. Negou ter denúncia de tráfico naquele dia específico, mas receberam denúncias e o ponto é conhecido pelo tráfico. Salientou que o réu falou residir lá com a companheira Aline. Narrou que já fez diligências naquele local, mas o réu nunca havia sido abordado. Negou que o réu tenha sido pressionado para apontar que comprou do Renato Cyman. Frisou que o réu disse ter pago um valor irrisório pelo aparelho, mas não se recorda quanto. Contou que o réu admitiu saber que era produto de furto, falou que o Renato era usuário e comprava droga dele. Informou que leram a autorização de entrada aos dois, eles leram e assinaram. Negou ter outras pessoas na casa. Destacou que havia duas balanças de precisão, não se recorda de resquícios de droga. Negou ter tido acesso ao celular de Aline e ter tido acesso a mensagens. Negou ter algemado Aline, ela tem crises de ataques epiléticos, ela se medicou e falou que recebe auxílio. Disse ter percebido que ela não tinha participação no tráfico. Negou ter pedido ao réu para gravar vídeo e ter tirado foto deles.

A informante Aline afirmou que é esposa do réu, de manhã ele voltou com esse celular, não sabe de quem comprou. Relatou que a droga era sua e do réu, para consumo próprio. mencionou que estavam usando quando a polícia chegou. Declarou ter recebido mensagem para sair que o lanche havia chegado, os policiais chegaram batendo no réu e na depoente, falando para assumirem que o celular tinha sido comprado de Renato Cyman. Disse que os policiais insistiram para dar conta de uma televisão, não tinha denúncia de tráfico em sua casa porque não tem. Negou que a droga tivesse em cima do rack, estava na cama. Narrou que depois que tinham levado o réu na viatura vieram com papel dobrado, não dava para ler o que estava escrito, era para assinar como testemunha, estava dobrado na prancheta. Falou que conhecia os policiais de vista, eles não têm problemas com o esposo porque ele não é de Assis. Esclareceu que a mensagem foi enviada pelo aparelho do Paulinho, a depoente tinha pedido um lanche para a filha, quando o réu abriu o portão já apanhou e depois viu que não tinha mais a mensagem, foi um moreninho que lhe bateu com tapas na cara. Negou ter tido diligência em sua casa atrás de drogas. Frisou que o celular estava carregando. afirmou que conhece Renato de vista e o réu não o conhece. Relatou que o réu faz manutenção de canos de piscina e nas horas vagas cata reciclagem. mencionou que as balanças estavam no bag de reciclagem. Declarou que viu e escutou os policiais agredindo o réu. Salientou que assinou a declaração

sem saber o que era, os policiais já entraram batendo. Falou que a tv foi achada perto da casa do Renato. Negou que ele frequentasse sua casa. Informou que conhecia o réu há quatro meses, antes ele morava em Foz do Iguaçu e mudou para Assis. Comentou que o réu não saía de casa e não andava sozinho na cidade. Negou ter desavença do réu com policial. Negou saber que o réu responde a uma acusação de tráfico de drogas no Paraná. Disse que comentou o ocorrido na Delegacia e ficou com medo porque foi abordada por policiais na rodoviária 15 dias depois da prisão, antes não registrou por ter medo de ser forjada pelos policiais. Negou ter problema com a polícia. Esclareceu que assinou a declaração no sofá de casa, quando o réu já estava na viatura.

Pois bem. Com a devida vênia ao combativo Advogado, não vislumbro a ilegalidade na realização de buscas na residência do réu. Há declaração expressa e devidamente firmada tanto por José Maria como por sua esposa Aline, autorizando o ingresso dos policiais na residência. O casal é alfabetizado e se de fato estivessem diante do cenário de abuso de poder que narraram, com certeza não assinariam um documento dobrado e sem saber de seu conteúdo.

Não bastasse, os policiais encontraram um celular objeto de furto na posse de José Maria, em nítido flagrante de crime de receptação. Nesse sentido, o STF já firmou tese que legitima a entrada forçada em domicílio “mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tese 280/STF – RE 603.616).

De igual forma vem decidindo os Tribunais:

(...) Sendo a receptação, na modalidade de ocultar, delito permanente, caracterizado estava o denominado “estado de flagrância” que permite o ingresso em residência e consequente busca e apreensão, sem necessidade de mandado judicial. Sobre a desnecessidade de mandado judicial, nas hipóteses de flagrantes de crimes permanentes, farto é o entendimento jurisprudencial. Além dos acórdãos citados pela d. Procuradoria Geral de Justiça a fl. 359, que enfocam justamente o delito de receptação, temos, entre outros, os seguintes: STJ: HC 452.760/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2018; HC 223.715/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15.02.2012 e HC 222.173/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22.11.2011. A respeito da inviolabilidade do domicílio e da necessidade de mandado judicial para busca e apreensão, Guilherme de Souza Nucci tece judiciosas considerações, “in verbis”: “INGRESSO ABUSIVO E CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE CRIME PERMANENTE: questão controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é saber se a invasão injustificada, a princípio, pois sem mandado e sem qualquer denúncia de flagrante, poderia consolidar e legitimar a descoberta da prática de um crime no seu interior, como é o caso, justamente, da guarda de substância entorpecente. Cremos que o caso concreto é o melhor fator de discernimento para a solução do aparente impasse. Se a polícia tem algum tipo de denúncia, suspeita fundada ou razão para ingressar no domicílio, preferindo fazê-lo por sua conta e risco, sem mandado porque às vezes a situação requer urgência pode ingressar no domicílio, mas a legitimidade de sua ação depende da efetiva descoberta do crime. Do contrário, pode-se caracterizar o crime de abuso de autoridade ou mesmo infração funcional. (...) A prova colhida no interior da casa, no entanto, segundo nos parece, é lícita, pois a infração penal estava em andamento, justificando a prisão e a punição do delinquente. Difere esta situação da obtenção da prova por meios ilícitos, quando não se está impedindo a ocorrência de um delito em franco desenvolvimento. (...) No segundo caso (crime permanente descoberto por acaso) havia o desenrolar de uma atividade criminosa, que cessou graças à interferência da polícia”. (“Código de Processo Penal Comentado”, 12ª. ed. pag. 569).” (TJSP - Apelação Criminal nº 1516042-16.2021.8.26.0228, Rel. Des. Augusto de Siqueira, julgado em 07/02/2022, destaquei).

Receptação – crime permanente – desnecessidade de autorização judicial para busca e apreensão. “O crime de receptação é de natureza permanente, tornando-se desnecessária a prévia existência de autorização judicial para a entrada na

residência do réu, haja vista cuidar-se de flagrante delito. Assim, a busca e apreensão levada a efeito na residência do réu, onde foram apreendidos aparelhos celulares de origem criminosa, guardou harmonia com os ditames do art. 5º, inciso XI, da CF e art. 240 do CPP, não havendo qualquer ato que a macule." (TJDFT - Acórdão 1301901, 07114808920198070003, Rel. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020, destaquei).

No caso concreto o réu foi abordado na posse de um dos objetos furtados de uma clínica no mesmo dia e pelo que os policiais falaram uma televisão também subtraída ainda não havia sido localizada. Portanto, com a devida vênias a posicionamentos díspares, entendo que a entrada dos militares na residência seria válida mesmo que forçada e sem expressa autorização dos moradores, devido ao fundado receio de se localizar também o televisor subtraído, notadamente pela proximidade temporal entre o crime de furto e o flagrante da receptação.

Por conseguinte, a busca e apreensão das drogas localizadas na residência do réu é válida pelo princípio da serendipidade, o qual instrui que o encontro fortuito de prova de crime novo durante a busca por informações de um fato diverso, é totalmente lícito.

Atualmente, a Suprema Corte sustenta que o encontro fortuito de provas não necessariamente precisa guardar relação com o crime originalmente investigado: "O Colegiado afirmou que a hipótese dos autos é de crime achado, ou seja, infração penal desconhecida e não investigada até o momento em que se descobre o delito. A interceptação telefônica, apesar de investigar tráfico de drogas, acabou por revelar crime de homicídio. Assentou que, presentes os requisitos constitucionais e legais, a prova deve ser considerada lícita. Ressaltou, ainda, que a interceptação telefônica foi autorizada pela justiça, o crime é apenado com reclusão e inexistiu o desvio de finalidade" (STF, Informativo 869 - HC 129678, j. 13/06/2017).

O réu e o douto Defensor tentam convencer que os policiais forjaram o flagrante ocorrido nestes autos para incriminar Renato Cyman, mas como não o encontraram incriminaram José Maria. Para acreditar na palavra do réu seria forçoso concluir que os policiais já soubessem que o celular furtado estava na posse de José Maria, tivessem conhecimento de que o mototaxista Paulo iria até a casa dele, tivessem o abordado antes disso, pegado seu celular, passado por Paulo na frente da casa do réu e quando este saiu da casa já o recebessem com agressões.

Todavia, não há nos autos nada que comprove tais alegações. Primeiro porque nada indica que desde o início os militares já suspeitavam que o réu estaria na posse de bens furtados. Eles relataram ter notícias do envolvimento do local com o tráfico de drogas e por isso patrulhavam por ali, viram indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Não mencionaram que estavam em busca de bens furtados ou mesmo que tivessem alguma informação de que eles pudessem estar na posse de José Maria. Tal desconfiança só surgiu após a revista pessoal, quando encontraram o celular furtado na posse do réu, o que autorizou o ingresso na residência em razão de haver outro bem subtraído que poderia estar ali, mas por fim viabilizou a localização de drogas.

Segundo porque, ainda que se pudesse cogitar que os policiais tinham essa informação prévia, seria quimérico afirmar que eles teriam como adivinhar que um mototaxista aleatório havia sido contratado pelo réu para levar um lanche até o local, abordá-lo antes de chegar na casa, apropriar-se do celular dele e mandar mensagem ao réu se passando pelo entregador, apenas para que conseguissem tirá-lo de dentro da casa e viabilizar a abordagem.

Embora o mototaxista tenha confirmado isso em solo policial, curiosamente a Defesa deixou de arrolá-lo como testemunha, para ser ouvido em juízo e sob o crivo do contraditório. Ademais, poderia ter feito prova do alegado com prints das mensagens enviadas ou recebidas, ou mesmo das ligações realizadas, mas nada juntou que pudesse sustentar estava versão.

Terceiro, e mais importante indicativo de que os fatos não se deram como narrado pelo réu, diz respeito às supostas agressões sofridas, pois não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a atuação policial. Pelo contrário, o laudo de lesão

corporal cautelar juntado a fl.28 atesta que o réu não apresentava qualquer lesão de interesse médico-legal quando do exame.

Ressalto que em três oportunidades diferentes o réu José Maria narrou fatos contraditórios sobre o assunto. Na delegacia contou que foi agredido com chutes, um na costela, e um soco na boca, mas não havia sinais das agressões. Na audiência de custódia disse que mostrou as marcas ao médico, mas sobre a lesão na boca disse que só a percebeu depois que o perito já havia feito o exame. Em Juízo asseverou que a boca sangrou e mostrou o ferimento ao perito.

No entanto, a fala do réu encontra-se isolada nos autos. Embora a versão tenha sido confirmada pela esposa, ouvida como informante, sem o compromisso de falar a verdade e tem interesse na absolvição do réu, por se tratar de pessoa intimamente ligada a ele.

Assim, não se vislumbra qualquer indício de ilegalidade na realização da busca domiciliar ou na atuação policial que pudesse ensejar a nulidade processual ou desentranhamento de provas e, considerando a validade dos atos impugnados, passo à análise específica de autoria de cada crime imputado ao requerido.

No tocante à receptação, o crime se caracteriza pela aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa que sabe ser produto de crime. É certo que no delito em análise a aferição do dolo do agente e da ciência da origem criminosa é difícil. Isto ocorre porque é praticamente impossível penetrar no íntimo do infrator e, via de regra, os crimes são cometidos na clandestinidade.

Conforme a jurisprudência, "o crime de receptação dolosa pressupõe crime antecedente e o receptador não pode ser responsabilizado sem que definitivamente se declare a existência desse pressuposto." (TJSP, RT 663/293). Está pacificado na doutrina e jurisprudência que se pode punir o autor da receptação mesmo quando desconhecido o autor do delito precedente, aliás, como determina o §4º, do art. 180, do Código Penal.

A aferição do elemento subjetivo deste tipo penal não dispensa análise circunstanciada das peculiaridades de cada caso e do agente, contrastadas com máximas de experiência, inclusive pela dificuldade de obtenção de prova direta, que, tirando situações especiais, somente poderia se dar por confissão.

Com efeito, a análise das circunstâncias, do comportamento e dos indícios é importante para aferir se houve ou não o crime, porque raramente ocorre a confissão e não se pode penetrar no foro do íntimo do agente para aferição do dolo. Ninguém admite, até porque o homem hesita em reconhecer o próprio erro, ter adquirido coisa que sabia ser de origem espúria.

No caso concreto os depoimentos colhidos na fase instrutória são aptos a comprovar que José adquiriu um celular que seria produto de crime. Nesse caso incumbe ao requerido demonstrar a aquisição legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:

PENAL. RECEPÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. PROVAS. ORIGEM ILÍCITA. CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. 1. Se o conjunto probatório demonstra ter o réu ciência da origem ilícita do bem adquirido, inviável o pleito absolutório. 2. Tratando-se de delito de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar a aquisição legítima do bem, por configurar hipótese de inversão do ônus da prova. Nesse sentido: TJDF - APR 20020710198509, DJU de 27.04.2007; TJDF - APR 200000110795625, DJU de 28.03.2007. Negou-se provimento. Unânime. (TJDF, APR nº 20040710174870 (295263), 2ª Turma Criminal, Rel. Vaz de Mello. j. 29.11.2007, DJU 12.03.2008, p. 142, destaquei).

PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exaustão, a detenção inocente. (TACRIM/SP, Apelação nº 1.327.667/1, 12ª Câmara, Rel.: Des. Ivan Sartori, j.10/03/03, RJTACRIM nº64/138, destaquei).

Em crime de receptação, a prova indiciária harmônica e concatenada, evidenciando, em especial, a posse da res pelo agente e a prática de atos que sugerem o conhecimento de sua ilicitude, bem como a ausência de justificativa verossímil, basta para sustentar um decreto condenatório. (...) (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0079.02.030172-1/001(1), 5ª Câmara Criminal, Rel. Hélcio Valentim. j. 10.04.2007, destaquei).

PROVA - Receptação - Indício como elemento de convicção - Admissibilidade: - Na receptação, é admissível considerar o indício como elemento de convicção, uma vez que esse crime exige o dolo específico, consistente em conhecer o autor a origem espúria do bem. Tal conhecimento existe apenas no intelecto do agente e, como objeto imaterial que é, torna impossível a prova direta, servindo a indiciária. (TACRIM/SP, Apelação nº 1.336.953/2 - 8ª Câmara - Relator: Francisco Menin - 26.6.2003 - Ementário nº 47, novembro/2003, pág. 27, destaquei).

A versão do acusado, de que não sabia que o celular seria produto de crime, não é crível porque segundo ele e a esposa (audiência de custódia e fls.89/90, respectivamente), José trabalhava com venda de produtos do Paraguai, portanto tinha ciência que estava adquirindo o aparelho por valor muito inferior ao preço de mercado.

Além disso, em seus depoimentos deu versões diferentes dos fatos, o que é indício de inverdade. Na delegacia disse que postou na rede social "Facebook" que queria comprar um celular, e Renato lhe ofereceu um aparelho por R\$ 500,00, pagou R\$ 100,00 e ficou devendo R\$ 400,00. Em Juízo falou que comprou de "Buiú", com quem pega reciclagem, por R\$ 500,00, pagou R\$ 100,00 e só pagaria o restante quando ele lhe entregasse a nota fiscal.

Malgrado José Maria tente convencer que os policiais o obrigaram a mentir na delegacia, dizendo que havia adquirido o celular de Renato Cyman, destaco que é desnecessário entrar no mérito da autoria do crime de furto, o que é objeto de investigação em separado e em nada ajuda o réu. Nestes autos basta a prova de que o bem subtraído estava na posse ilegítima de José Maria, o que foi constatado, sendo irrelevante de quem adquiriu.

Enfim, estando o réu na posse do celular subtraído, tendo adquirido o aparelho por um valor muito baixo perante o valor de mercado, tendo pago apenas R\$ 100 ao vendedor e sem se preocupar em pegar a nota fiscal do aparelho, sem contar as mudanças de versão sobre a aquisição, são elementos que indicam a plena ciência acerca da origem espúria do bem.

No caso, os elementos de prova são indícios claros que traduzem a certeza de que o réu praticou o crime de receptação, na forma dolosa, principalmente porque não foram contrariados por nenhum elemento probatório seguro.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, o delito se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e antecedentes do agente.

De acordo com a prova testemunhal produzida, os policiais narraram em Juízo que patrulhavam o local por já ser conhecido como ponto de venda de drogas e tinham informações de que estava ocorrendo o tráfico ali. No dia dos fatos avistaram o réu em atitude suspeita, segundo o policial Rômulo ao ver a viatura ele demonstrou nervosismo e tentou entrar rapidamente na casa, razão pela qual decidiram abordá-

lo. Em sua posse estava um aparelho celular que constatarem pelo IMEI ser produto de um furto que havia acontecido na mesma data.

Tendo em vista que no mesmo crime havia sido subtraído um televisor, os policiais deliberaram por realizar buscas na residência e, mesmo em estado de flagrância por crime permanente de receptação colheram declaração expressa dos moradores, autorizando o ingresso na residência, onde localizaram 17 porções de cocaína, além de duas balanças de precisão.

Embora o réu e sua esposa neguem que a abordagem tenha sido realizada dessa forma e afirmem que as drogas eram para consumo pessoal, a versão deles foi desmentida pelos depoimentos dos policiais, que, demonstrando coerência e isenção de ânimos, descreveram o ocorrido, merecendo, assim, a fé deste juízo.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323).

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei).

Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...]" (STJ HC 149.540/SP 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011 DJU 04.05.2011, destaquei).

"O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos". (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei).

Cumprе ressaltar que o réu não demonstrou que os agentes da lei teriam algum motivo para incriminá-lo gratuitamente, mesmo porque, até há pouco tempo José Maria não residia neste Estado. Ele e a esposa afirmaram que não conheciam os policiais, nunca foram abordados por eles antes e que não havia motivos para que eles o incriminassem gratuitamente.

Em verdade, o réu buscou se exculpar do crime, todavia não trouxe elementos concretos de que pudesse existir qualquer animosidade entre eles. Portanto, não entrevejo fundadas razões que abalem a fé pública dos agentes.

Ao contrário dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, que foram harmônicos e coesos sempre que ouvidos, o depoimento do réu possui várias incongruências que colocam em dúvida a veracidade de seus relatos.

A primeira e mais contundente diz respeito às supostas agressões sofridas, o que já foi mencionado nesta sentença e dispensa novos comentários.

A segunda é que o acusado narrou em Juízo que as balanças de precisão não lhe pertenciam, estavam na reciclagem e sequer funcionavam. Antes, na delegacia, José Maria havia assumido a propriedade dos objetos, mas afirmou que estavam estragadas e enquanto funcionavam as utilizava para pesar as drogas que comprava para seu uso pessoal.

Entretanto, não é crível que um usuário pese as drogas que compra para uso próprio. Pelo contrário, é um petrecho tipicamente usado por traficantes para pesar e embalar as drogas que vendem. Além disso, ao contrário do sustentado pelo requerido, o laudo pericial de fls.72/73 aponta que uma das balanças estava funcionando perfeitamente.

A terceira contradição consiste no local de compra da droga, a quantidade que tinha

e quanto teria pagado. Em seu interrogatório policial disse que comprou de um indivíduo no Jd. Maria Isabel e sempre manda entregar a droga de moto, comprou a prazo por R\$ 220,00. Em Juízo, declarou que as adquiriu na Praça Prudenciana, por R\$ 250,00 em dinheiro. Disse que havia comprado 5gr, mas o peso líquido da droga foi de 10,4gr (fl.23).

Além das divergências apontadas, José Maria escreveu uma carta a este Juízo contando uma outra versão dos fatos, totalmente nova (fls.121/122). Narrou que guardava as drogas e as balanças de precisão para terceira pessoa, a quem devia dinheiro e lhe pediu esse favor como quitação da dívida. Ressaltou que a esposa sequer sabia da existência dos entorpecentes. Nesse ponto ressaltou que o simples fato de guardar drogas para consumo de terceiros já tipifica a conduta.

Vale salientar que os entorpecentes encontrados estavam divididos em várias porções, prontas para a venda. Quando ouvido na delegacia, José Maria admitiu ter feito "17 balas" com as drogas, para que ele e a esposa usassem durante a semana. Porém, se as drogas eram para consumo pessoal deles próprios não teria por que as embalar como se para venda fossem.

Enfim, as prévias denúncias recebidas pelos policiais; aliadas à localização de drogas já divididas em várias porções, prontas para a venda; além das inúmeras contradições evidenciadas nas versões contadas pelo réu; e a apreensão de balanças de precisão, petrechos tipicamente usados por traficantes, são indicativos de que estava praticando o crime do art. 33.

Em que pese o réu tenha dito ser mero usuário, isso não impede que seja traficante. Mesmo a mais inocente das criaturas sabe que traficantes do final da cadeia delitiva deixam consigo, de propósito, uma quantia não muito grande de narcóticos, justamente para fingirem à Polícia que são meros usuários - sujeitos a sanções penais ridículas - e não traficantes, que infernizam a vida não só dos infelizes viciados, mas de todas as pessoas próximas a eles: pais, mães, irmãos, parentes, amigos etc.

Sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefando até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprova que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio.

O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que as drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio. Assim, não é possível desclassificar a conduta para o porte de drogas para o uso próprio.

Destarte, o conjunto probatório é harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo tráfico e receptação, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente:

A culpabilidade do réu, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é elevada para a espécie, considerada a natureza do delito. Ele é primário e não ostenta maus antecedentes, eis que por entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça processos penais em andamento não podem ser contados como maus antecedentes. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. As consequências do crime foram normais para a espécie.

Na primeira fase, considerando a inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena-base em: a) 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo tráfico; b) 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela receptação.

Na segunda fase está presente a atenuante da menoridade relativa, já que era menor de 21 anos quando do crime. Reconheço também a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública

causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Portanto, compenso uma agravante pela atenuante e mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar.

Na terceira fase não há causas de aumento de pena. Deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de maus antecedentes e de indícios de que se dedique a atividades criminosas e integre organização ilícita, ainda que o réu responda por outro crime. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j.11/11/20).

A Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça aderiu ao precedente da Suprema Corte. A propósito: AgRg no AgRg no HC 654.773/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10/8/2021, DJe 16/8/2021; AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/8/2021, DJe 16/8/2021. A Quinta Turma do STJ também passou a julgar dessa mesma forma, conforme se extrai da decisão do HC 664.284 - ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.21/09/2021. Em razão da pacificação dessa questão pelos Tribunais Superiores é caso de observar o precedente.

Não vejo inconstitucionalidade neste dispositivo, pois o legislador quis tratar de maneira menos rigorosa o traficante ocasional; houve exasperação da pena para o tráfico em comparação com a antiga Lei nº 6.368/76, de modo que não se justificava um tratamento igualitário entre o traficante profissional e o eventual. Está aí a razão da causa de diminuição em apreço, apta a realizar (e não a maltratar) o princípio da isonomia. O teste de constitucionalidade, à luz do princípio da isonomia, deve ser realizado no âmbito do microssistema da Lei de Drogas, não se podendo fazer comparações com outros crimes previstos na legislação penal. Para a definição do total de diminuição da pena deve ser levado em conta a quantidade de droga apreendida e a potencialidade lesiva dela. Este é o posicionamento da jurisprudência majoritária e foi respaldado em recente julgado da 1ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme acórdão adiante colacionado aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO

AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO PELO RECURSO CABÍVEL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E AUMENTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM 1/6 (UM SEXTO) EM DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira